

1501607-46.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (grifo nosso).

A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º ("tráfico privilegiado") deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma interpretação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501607-46.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501607-46.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2205936/2022 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 26437335 -

06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2205936 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Priscila de Oliveira Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

PRISCILA DE OLIVEIRA COSTA, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 29 de julho de 2022, por volta das 10h50, na Rua João Antônio de Souza, nº 01, bairro Ferrazópolis, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, trazia consigo, para fins de comercialização, drogas consistentes em: 17g de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 09 invólucros plásticos; 25g de cocaína, acondicionadas em 36 invólucros plásticos; e 6g de cocaína na forma de

crack, acondicionadas em 24 eppendorfs, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 08 e laudo de constatação de págs. 24/27.

Segundo o apurado, na data e local acima indicados, a acusada trazia consigo, para fins de venda, sessenta e nove embalagens individuais de drogas.

Consta dos autos que policiais militares receberam via COPOM a informação de que duas mulheres traficavam drogas no local dos fatos, para onde se dirigiram.

Ali chegando, os policiais avistaram um grupo de aproximadamente seis pessoas, com duas mulheres, razão pela qual deliberaram pela abordagem.

Durante revista pessoal, uma policial feminina encontrou trinta e seis porções de cocaína, vinte e quatro eppendorfs com crack, e nove embalagens de maconha escondidos no sutiã da acusada, além da quantia de R\$ 863,75 (oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Indagada, a acusada admitiu informalmente que as porções de entorpecentes lhe pertenciam, que as demais pessoas do grupo eram apenas usuários, e que ela traficava drogas há dois dias.

Diante disso, PRISCILA foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a sua forma de acondicionamento, a apreensão de dinheiro, bem como as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante revelam a prática do tráfico de entorpecentes.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial a págs. 04/45. Notificada (pág.57), a acusada ofertou defesa preliminar (págs.81). Recebida a denúncia (págs.93/94), a ré foi citada (pág. 106). Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas da acusação, interrogando-se a ré.

Em debates, o Ministério Público requer a condenação da ré nos termos da denúncia e a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena, reconhecido o tráfico privilegiado. A defesa requer a absolvição por negativa de autoria ou, ainda, insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente praticado pela acusada, inexistindo dúvida quanto à autoria.

A materialidade delitiva está demonstrada no auto de exibição e apreensão a pág.08 (aparelho celular, dinheiro e droga); nos laudos de constatação (págs.24/27) e químico-toxicológico (págs.90/92), no laudo pericial de págs. 107/108 (aparelho celular), bem como no comprovante de depósito juntado a pág.76/77.

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág.12), em Juízo a acusada confessou a prática do crime nos termos da denúncia. Acrescentou que o dinheiro apreendido era oriundo da venda de droga. Para justificar a conduta, declarou que passava dificuldade financeira.

Precisava pagar o aluguel da casa onde mora com as duas filhas menores e optou pelo tráfico de droga, na data do fato, porque estava desempregada.

A ré confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

"Tem se entendido que "a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de autoacusação falsa" (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A confissão vem corroborada, sob o crivo do contraditório, nos depoimentos dos policiais militares Maurício Soares do Carmo e Wellington Bruno de Almeida Barbosa, que em relato coeso e harmônico com o anterior, informaram os passos da diligência encetada na data do fato e espanearam qualquer dúvida acerca da existência do crime:

Receberam, via COPOM, informação de que uma mulher realizava o tráfico de droga em local conhecido pela venda de substâncias entorpecentes e para lá se dirigiram. Deparam-se com grupo de aproximadamente seis pessoas. Durante revista pessoal, uma policial feminina encontrou porções individuais de cocaína, crack e maconha escondidos no sutiã da acusada, em quantidade típica do tráfico, além da quantia de R\$ 863,75 (oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). Com os demais, que se declararam usuários de droga, nada foi encontrado.

Indagada, a acusada admitiu que as porções de droga se destinavam à venda, assumindo a mercancia ilícita. Disse que os demais indivíduos que a acompanhavam eram apenas usuários. A ré não estava sob efeito de droga.

Diante disso, PRISCILA foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Inexiste o mínimo indício de que os policiais tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial à ré, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015).

A ausência de qualificação de civis como testemunhas, por si só, não leva à absolvição da agente, diante da conhecida dificuldade de tal diligência ante a 'lei do silêncio' que incide nas 'biqueiras' desta Comarca.

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a variedade e a espécie de substância entorpecente apreendida (09 invólucros plásticos de maconha, 36 invólucros plásticos de cocaína e 24 eppendorfs de crack), a forma como acondicionada (individualmente), a apreensão de dinheiro trocado (R\$863,75) e as circunstâncias da prisão (denúncia anônima descrevendo mulher como autora do tráfico de droga e apreensão da droga e dinheiro no sutiã da ré), tornam evidente que a droga se destinava ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, conforme preconiza o artigo 28, §2º, do citado Diploma.

Anote-se que a circunstância da ré não ter sido presa no momento em que efetuava a venda da droga a usuário, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia. Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consuma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo

33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, sendo suficiente a identificação da finalidade mercantil.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pela ré.

Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício da acusada, ausente prova nesse sentido.

Para justificar a conduta criminosa, a acusada declarou que passava por dificuldade financeira. Estava desempregada e precisava pagar o aluguel do imóvel onde morava com as filhas.

Não merece guarida a tese do estado de necessidade.

A dificuldade financeira, por si só, não configura a discriminante. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência da agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida. De tal ônus a ré não se desincumbiu a contento.

Inexiste nos autos prova da situação de extrema necessidade da acusada, muito menos que agira visando proteger-se de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa, elementos mínimos necessários para acolhimento da excludente, não se desincumbindo, portanto, do ônus insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Eventual dificuldade financeira, que nem sequer foi provada, não autoriza, de per si, a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. A ré teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha: "(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade.

Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade.

Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

Portanto, a acusada realizou conduta típica - artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - antijurídica e, em face de sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Analisados os fatores de individualização da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis à acusada,

primária e sem antecedentes criminais, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Não há agravantes a considerar. Embora presente a confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), deixo de reduzir a reprimenda porque as atenuantes não permitem a sua fixação do mínimo legal previsto em lei para o crime (Súmula 231 do STJ).

Não há causas de aumento de pena.

Incide a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. A ré preenche todos os predicados legalmente previstos. É primária, não ostenta antecedentes criminais e não há prova de que se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa.

Não há óbice à aplicação do índice redutor máximo, não se sobressaindo, no fato em tela, maior grau de censurabilidade na conduta da agente, que se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie.

Assim, pelas razões alhures, reduzo a pena no máximo legal de 2/3, o que perfaz 01 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

O valor de cada dia-multa, ante a aparente situação econômica da ré, será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento de pena é o aberto.

Não se desconhece que boa parte da jurisprudência entende que a causa especial de diminuição de pena não altera a tipificação contida no caput do referido preceito legal (ou seja, em que pese a possibilidade de se aplicar um abrandamento na reprimenda do agente, a prática do "tráfico privilegiado" continua a ser considerada tráfico de drogas, ainda hediondo).

Esse entendimento chegou a ser reforçado pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas." (Súmula 512, Terceira Seção, julgado em 11/06/2014).

Ocorre que, no julgamento do HC nº 118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Para o Supremo Tribunal Federal, havia evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos (Lei 8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo apresentam contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência. Essa decisão foi acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, em 2016.

Ainda assim, tais decisões encontravam-se desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam adstritos ao entendimento ali professado.

Ante a inexistência de resolução do Senado acerca do assunto em debate, tampouco edição de Súmula Vinculante nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram seu posicionamento de que o "tráfico privilegiado" era equiparado a crimes de natureza hedionda.

Esse foi no entendimento perfilhado por este Juízo por anos, mantendo-se a natureza de crime hediondo mesmo ao agente que recebia os beneplácitos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Ocorre que a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime") trouxe uma inflexão ao debate.

Isso porque, dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado": "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (grifo nosso).

A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas

previsto no §4º (“tráfico privilegiado”) deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução histórica, que aos poucos se fortificou no sentido de considerar o “tráfico privilegiado” como crime comum, exatamente pelo fato de que tais delitos “apresentam contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência”.

Adotar uma premissa válida para a Lei de Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma justificativa excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal incongruente, teratológico, uma vez que seriam aplicados “dois pesos e duas medidas”.

A persecução penal, fundamentalmente, está separada em três fases bem distintas, a saber: a investigação, o processo judicial de conhecimento e a derradeira, sua fase de execução. Ora, como é possível o legislador não considerar o tráfico privilegiado perante o Juízo de Execução como crime hediondo, dizendo com todas as letras tratar-se de crime comum, e, ao revés, continuar sendo crime hediondo perante o juiz do processo de conhecimento.

O direito é único.

No entanto, o direito, como ciência que é, está sujeito a alterações de acordo com a realidade e a acomodação social, possibilitando, sempre, sua interpretação e modificação de entendimento, no todo, ou em parte.

Por tais razões, este Juízo alterou, nessa parte, posicionamento anterior, depois de muita reflexão e ponderação, para pensar de maneira diferente o assunto relacionado ao denominado “tráfico privilegiado”, conferindo benefícios ao agente, quer no que respeita ao montante da reprimenda, quer em relação ao regime inicial para expiação da pena corporal.

Diante das alterações legislativas recentes, deve ser realizada interpretação sistemática, passando-se a adotar o tráfico privilegiado como crime comum, de maneira que o regime mais adequado no contexto dos presentes autos, de acordo com os parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, deve ser o aberto.

Fundamenta-se o regime na exegese do artigo 59, caput, e seu inciso III, do Código Penal, a qual faculta ao magistrado, dentre todas as peculiaridades do processo, suas consequências, e atendendo aos outros predicados do citado artigo, estabelecer a pena concreta dentre aquelas cominadas, bem como o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A pena base foi fixada no mínimo legal. A ré é primária, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedica à atividades criminosas (o quantum de droga apreendido em seu poder e as condições subjetivas que apresenta não levaram a tal conclusão). Confessou a prática do crime. Sendo assim, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Cumpre-se, outrossim, a recente decisão emanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP.

De outra parte, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do “sursis”, não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. A concessão de tais benesses descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Embora seja possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito não constitui medida recomendável pois não teria o condão de alcançar os fins colimados com a aplicação da pena e da lei penal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar a acusada PRISCILA DE OLIVEIRA COSTA, qualificada nos autos às págs. 21/23, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual a CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme retro detalhado.

A acusada respondeu ao processo solta, sem percalços. Não estando presentes os requisitos da prisão preventiva poderá recorrer em liberdade.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido e depositado nos autos (comprovante a pág.76/77), oriundo do tráfico de droga, bem como do aparelho celular usado pela acusada para a prática da mercancia ilícita, em favor da União, nos termos da Lei nº 11.343/06.

De plano, não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos;

Oportunamente, comunique-se Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome da ré no rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação da ré, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) em relação à pena de multa, observe-se os parágrafos do artigo 479-A e 480, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, assim como o Provimento CG 05/22, providenciando-se o necessário.

d) Providencie-se a transferência do numerário apreendido nos autos para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD, informando sobre a decretação do perdimento da quantia apreendida e o local do depósito (comprovante de depósito juntado a pág.76/77).

e) Oficie-se à Autoridade competente para destruição do aparelho celular apreendido, considerando-se reduzido e insuficiente o valor do bem para cobrir o custo gerado por eventual leilão realizado pelo Poder Público.

Custas pela ré no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA